

1053373-95.2022.8.26.0053

Classe: Mandado de Segurança Cível

Assunto: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física

Magistrado: GISELA AGUIAR WANDERLEY

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 2ª Vara de Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... na maioria das vezes, com o tráfico de drogas. [...]. Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

2ª Vara de Fazenda Pública

Processo nº 1053373-95.2022.8.26.0053

Processo:

1053373-95.2022.8.26.0053 - Mandado de Segurança Cível

Impetrante:

Luciano de Oliveira e Silva

Impetrado:

Secretária Municipal de Segurança Urbana da Cidade de São Paulo e outro

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por LUCIANO DE OLIVEIRA E SILVA em face do SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA DA CIDADE DE SÃO PAULO e INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE, todos já qualificados nos autos.

Narra o impetrante, em suma, que foi eliminado do concurso público para ingresso no cargo de guarda civil metropolitano em razão de ter altura mínima de 1,683 metro, inferior à exigência de altura mínima constante do edital (1,70 metro). Defende que a exigência editalícia, conquanto formalmente legal, é desarrazoada.

Com isso, pleiteia, inclusive em caráter liminar, a concessão da segurança a fim de que seja anulada a sua eliminação do certame, a fim de que possa participar das fases subsequentes.

A inicial veio instruída com documentos.

A gratuidade da justiça foi deferida (fls. 145)

A liminar foi deferida a fim de suspender a eficácia do ato de exclusão do impetrante em função do não atendimento da altura mínima exigida no edital e, por conseguinte, determinar a participação do impetrante nas fases subsequentes do certame, até o julgamento definitivo da demanda.

Notificada, a Secretária Municipal de Segurança Urbana prestou informações. Alega que o impetrante aceitou os termos do edital ao candidatar-se à vaga e que alterar o regramento neste momento feriria a isonomia do certame. Aduz, ainda, não haver direito líquido e certo e que o edital não pode ser atacado diretamente (Súmula 266/STF). No mesmo sentido veio a informação prestada pelo IBADE.

O Ministério Público manifestou-se a fls. 182/188 pela concessão da ordem.

É o relatório.

A ação constitucional de mandado de segurança visa à tutela de direito líquido e certo em face de ilegalidade ou abuso de poder praticados por autoridade pública ou

por agente particular no exercício de atribuições do Poder Público, na forma do art. 5º, LXIX, da Constituição da República de 1988 (CR/88) e do art. 1º da Lei n. 12.016/09.

O direito líquido e certo é definido como aquele cujo fato constitutivo é demonstrável de plano, vale dizer, mediante apresentação de prova pré-constituída. Assim, pela interpretação a contrario sensu da Súmula 625/STF, afastam-se da tutela pelo mandado de segurança além dos direitos amparáveis por habeas corpus e habeas data, quais sejam, os direitos à liberdade de locomoção e à autodeterminação informativa, respectivamente, os direitos cujos fatos constitutivos dependem de certificação quanto à matéria fática, vale dizer, aqueles que dependem de dilação probatória.

Quanto à preliminar de inadequação da via eleita, deve ser rejeitada. O pedido formulado neste mandado de segurança é de anulação do ato administrativo de exclusão do impetrante do concurso público, e não diretamente de declaração de ilegalidade da previsão editalícia, a qual simplesmente serve como causa de pedir, razão pela qual inaplicável a Súmula 266/STF ao presente writ.

A controvérsia cinge-se à validade da exigência editalícia de altura mínima de 1,70 metro para ingresso na carreira de guarda civil metropolitano do Município de São Paulo, à luz do princípio da razoabilidade.

O controle jurisdicional dos atos praticados no curso de concursos públicos cinge-se ao exame da sua legalidade, aí incluída a observância às normas constitucionais e legais regentes da matéria, bem como às normas editalícias que regem o certame. Estas, com efeito, estão estritamente vinculadas à tutela da isonomia, princípio constitucional que rege a atuação da Administração Pública, nos termos do caput do art. 37 da CR/88.

Portanto, a intervenção judicial sobre atos praticados durante a realização de concurso público deve se circunscrever ao controle de sua validade (conformidade ao ordenamento jurídico), e, em regra, não pode invadir questões meritórias atinentes aos meios e critérios de avaliação dos candidatos, abrangidas pela esfera legítima de discricionariedade técnica da Administração.

No controle de legalidade dos requisitos de competência, finalidade e forma do ato administrativo, o exame jurisdicional é amplo e integral, pois tais requisitos são pré-definidos (vinculados) pela lei. Já no controle da legalidade do motivo e do objeto do administrativo, no caso dos atos administrativos discricionários (definição do motivo/objeto a partir de juízo de conveniência/oportunidade pelo agente público, autorizado pela lei), o exame jurisdicional é restrito à razoabilidade (ou proporcionalidade) do ato administrativo, aferida a partir da compatibilidade entre a finalidade almejada e o meio empregado. O controle judicial do mérito do ato administrativo discricionário, portanto, não pode implicar a substituição do exame de conveniência/oportunidade, exclusivo do agente público no exercício da função administrativa, pois deve abarcar tão somente a aferição da razoabilidade (ou proporcionalidade) do ato, sem o qual este se revela ilegal (incompatível com a ordem jurídica). Nesse sentido: “[p]ara um ato estar de acordo com a lei, deve ser razoável e proporcional. Desse modo, a falta de proporcionalidade atinge, na verdade, a legalidade do ato; por isso, pode ser anulado pelo Judiciário” (TRINDADE, João; SCATOLINO, Gustavo. Manual de Direito Administrativo. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 72-73).

Assim, vale notar que o princípio da isonomia entre os candidatos não serve de óbice ao controle de validade (constitucionalidade e legalidade) do ato administrativo exercido pelo Poder Judiciário diante do exercício do direito de ação pelos candidatos que se reputam prejudicados por previsões legais ou editalícias inválidas.

A respeito da exigência de altura (estatura) e peso (massa) mínimos para ingresso em cargo público da área de segurança pública, colhe-se da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça a validade de tal exigência, desde que prevista em lei (em sentido formal e material) e no edital do concurso. Nesse sentido, por todos, cf. STF, RE 593.198 AgR, Primeira Turma, j. 6.8.2013; STF, RE 1.350.447 AgR, Segunda Turma, j. 11.03.2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.590.450/PE, Segunda Turma, j. 19/10/2017, AgRg no RMS n. 45.887/GO, Primeira

Turma, j. 4/9/2014.

Não obstante, a despeito da legalidade em sentido formal, a análise da altura ou do peso fixado como mínimo deve ser feita à luz do princípio da razoabilidade, conforme acima destacado. Assim, a altura ou o peso fixado como mínimo para ingresso na carreira (objeto do ato administrativo) depende da indicação da razão pela qual a altura ou o peso inferior ao mínimo seria incompatível com o exercício do cargo público (motivo do ato administrativo).

Uma vez firmadas tais premissas, no caso, foi fixada como mínima a altura de 1,70m (sexo masculino) e 1,60m (sexo feminino) para ingresso na carreira de guarda civil metropolitano. Tais parâmetros mínimos possuem previsão em lei em sentido formal e material (Lei n. 16.239/15, art. 12, § 2º).

Contudo, tais parâmetros mínimos, que geraram a eliminação do impetrante do concurso público, padecem de falta de razoabilidade, sobretudo quando comparados com a altura mínima exigida para outros cargos de segurança pública ou mesmo cargos de carreiras militares.

Com efeito, para ingresso na carreira militar do Exército Brasileiro (oficiais e praças), a altura mínima exigida é de 1,60m (sexo masculino) e de 1,55m (sexo feminino) - Lei n. 12.705/12, art. 2º, XIII.

De igual modo, para ingresso na carreira militar da Polícia Militar do Estado de São Paulo (oficiais e praças, inclusive bombeiros), a altura mínima exigida é de 1,60m (sexo masculino) e de 1,55m (sexo feminino) - Lei Complementar Estadual n. 1.291/16, art. 2º, IV.

A comparação entre as atribuições dos militares do Exército e da Polícia Militar com as atribuições dos guardas civis metropolitanos faz exsurgir a falta de razoabilidade da exigência mais rigorosa de altura mínima para este último cargo público.

Com efeito, os militares do Exército atuam, no plano externo, na defesa do país, em operações eminentemente terrestres e, no interno, pela garantia da lei, da ordem e dos poderes constitucionais, inclusive com o emprego de armas, via atuação estratégica, tática e operacional, à luz do art. 142 da Constituição da República (CR/88). Já os policiais militares atuam, no plano interno, com a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública (CR/88, art. 144, § 5º). Já os guardas civis metropolitanos, por sua vez, são incumbidos de atribuição dotada de menor complexidade, qual seja, a proteção de bens, serviços e instalações nos termos da lei (CR/88, art. 144, § 8º).

Assim, à luz do art. 144, § 8º, da CR/88, as atribuições das guardas civis municipais circunscrevem-se, em resumo, à vigilância patrimonial dos bens do Município, e não envolvem o exercício precípua monopólio da violência, com a realização de operações e confrontos físicos e até mesmo armados, o que é inerente à atuação do Exército e da Polícia Militar.

Sobre o tema: “[A] Constituição Federal de 1988, apesar das investidas em contrário, não autoriza os Municípios a instituírem órgãos policiais de segurança, pois as Guardas Municipais só podem ser destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, o que equivale dizer que o município não pode ter Guarda que substitua as atribuições da Polícia Militar” (LAZZARINI, Álvaro. Temas de direito administrativo. São Paulo: RT, 2003. p. 95).

Nesse rumo, vale notar que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), a guarda civil municipal não tem a mesma amplitude de atuação das polícias. Trata-se de instituição com atribuição preponderante de vigilância patrimonial, a qual não exerce de modo primário o monopólio estatal da violência, atribuição precípua das polícias – daí porque inclusive as guardas municipais não são sujeitas a controle externo pelo Ministério Público (CR/88, art. 129, VII).

Com efeito, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) vem afirmando a inconstitucionalidade da alteração de denominação da Guarda Civil Municipal para Polícia Municipal, justamente em razão da diversidade de atribuições de tais instituições: “[A] guarda municipal é força de natureza civil destinada à proteção de bens, serviços e patrimônio municipal, sem se imiscuir na Segurança Pública preventiva e ostensiva de atribuição dos Estados e União – Inconstitucionalidade

das guardas municipais adotarem a identificação de 'polícia', e ainda mais como 'militar', dada sua natureza civil" (TJSP, ADI n. 2286983-23.2019.8.26.0000, Órgão Especial DJe 24/6/2020). No mesmo sentido: TJSP, ADI n. 2205744-26.2021.8.26.0000, Órgão Especial, DJe 31/3/2022.

Não em outro sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em paradigmático julgamento, afirmou que a competência das guardas civis municipais se limita à tutela do patrimônio municipal e não inclui as atividades ostensivas e investigativas típicas das polícias atribuições da guarda civil municipal: "A Constituição Federal de 1988 não atribui à guarda municipal atividades ostensivas típicas de polícia militar ou investigativas de polícia civil, como se fossem verdadeiras "polícias municipais", mas tão somente de proteção do patrimônio municipal, nele incluídos os seus bens, serviços e instalações. A exclusão das guardas municipais do rol de órgãos encarregados de promover a segurança pública (incisos do art. 144 da Constituição) decorreu de opção expressa do legislador constituinte – apesar das investidas em contrário – por não incluir no texto constitucional nenhuma forma de polícia municipal. [...]. É possível e recomendável, dessa forma, que exerçam a vigilância, por exemplo, de creches, escolas e postos de saúde municipais, de modo a garantir que não tenham sua estrutura física danificada ou subtraída por vândalos ou furtadores e, assim, permitir a continuidade da prestação do serviço público municipal correlato a tais instalações. Nessa esteira, podem realizar patrulhamento preventivo na cidade, mas sempre vinculados à finalidade específica de tutelar os bens, serviços e instalações municipais, e não de reprimir a criminalidade urbana ordinária, função esta cabível apenas às polícias, tal como ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas. [...]. Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais. Poderão, todavia, realizar busca pessoal em situações absolutamente excepcionais – e por isso interpretadas restritivamente – nas quais se demonstre concretamente haver clara, direta e imediata relação de pertinência com a finalidade da corporação, isto é, quando se tratar de instrumento imprescindível para a tutela dos bens, serviços e instalações municipais. Vale dizer, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se houver, além de justa causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, o que não se confunde com permissão para realizarem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária" (REsp 1.977.119/SP, Sexta Turma, j. 16.8.2022), sem grifos no original.

No mesmo sentido: HC n. 742.578/SP, Sexta Turma, DJe de 19/9/2022; AgRg no HC n. 771.705/SP, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022.

Em tal cenário, verifica-se que, pela repartição de competências fixada pela Constituição da República, as atribuições dos guardas civis municipais não podem ser consideradas mais intensas e conflituosas do que aquelas exercidas pelas polícias. Logo, a exigência de altura mínima para guarda civil municipal em patamar superior àquele exigido para policial militar ou mesmo militar do Exército é dotada de falta de razoabilidade e se insere na tendência – já reconhecida como inconstitucional pelo STJ e pelo TJSP – de atribuir às guardas civis municipais atribuições exclusivas das polícias.

Nesse cenário, vale notar que, da leitura das informações prestadas pela autoridade pública coatora (Secretaria Municipal de Segurança Urbana), não houve a indicação de nenhum motivo para altura mínima exigida, a fim de permitir a aferição da razoabilidade do requisito a despeito do requisito mais brando das corporações militares. Daí ser o caso de confirmar a liminar e conceder a segurança. Portanto, em resumo, a exigência legal que gerou a eliminação impugnada padece de

inconstitucionalidade, pois incompatível com a atribuição dada às guardas municipais no art. 144, § 8º, da CR/88, de menor complexidade do que aquela conferida ao Exército e às polícias militares. Há violação ao princípio da razoabilidade e não se vislumbra, mesmo após a apresentação de informações pela parte impetrada, motivo que justifique a fixação de altura mínima mais rigorosa para a Guarda Civil do que aquela exigida para o Exército Brasileiro e a Polícia Militar do Estado de São Paulo (a qual é atendida pelo impetrante).

Ante o exposto, CONFIRMA-SE a liminar e, no mérito, CONCEDE-SE A SEGURANÇA, a fim de que ANULAR o ato de reprovação do impetrante do concurso público em razão do não atendimento do requisito de altura mínima e, sucessivamente, DETERMINAR a sua reinclusão no certame, a fim de que possa participar das fases subsequentes do concurso público.

Por consequência, EXTINGUE-SE O PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, c/c art. 14 da Lei n. 12.016/09.

Sem custas. Sem honorários (Lei n. 12.016/09, art. 25).

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Publique-se. Intimem-se, inclusive o Ministério Público.

Comuniquem-se as autoridades coatoras, na forma do art. 13 da Lei n. 12.016/09.

Serve a presente como ofício comunicatório. Autoriza-se o(a) advogado(a) a entregar o presente ao destinatário, comprovado o protocolo nos autos no prazo de 10 (dez) dias. Eventual resposta deverá ser encaminhada ao endereço eletrônico deste Juízo.

Sentença submetida a duplo grau de jurisdição (Lei n. 12.016/09, art. 14, § 1º).

Transitada em julgado, arquivem-se.

São Paulo, 20 de outubro de 2022.

GISELA AGUIAR WANDERLEY

Juiz(a) de Direito (assinado digitalmente)